

OSMAN B. ALIAS

lwn

ROHANA BT. RAZALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 17hb. Jun 2019/ 13 Syawal 1440H]

Kes Rayuan No. 10000-028-0131-2017

[Rayuan Perintah Hadhanah di bawah seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Perayu: En. Musa b. Awang dari Tetuan M.A. & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang dikemukakan oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 24/10/2017 di dalam kes no. 10400-028-0379-2015. Di dalam kes tersebut, Responden telah menuntut hak jagaan 3 orang anak dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Muhammad Rayyan Adam b. Osman hendaklah diserahkan kepada Plaintiff (ibu) berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Muhammad Haikal Firdaus b. Osman dan Muhammad Ikmal Firdaus b. Osman hendaklah diserahkan kepada Plaintiff(ibu) berdasarkan seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- iii. Defendan (bapa) hendaklah diberi hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah terhadap anak-anak tersebut dengan memaklumkan kepada Plaintiff terlebih dahulu dan lawatan tersebut hendaklah tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut.
- iv. Hak berhari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha bersama anak-anak tersebut hendaklah dijalankan secara bergilir-gilir dengan hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha pada tahun 1439H anak-anak tersebut akan bersama Plaintiff manakala hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha pada tahun 1440H anak-anak tersebut akan bersama Defendan. Kaedah ini hendaklah berterusan pada tahun-tahun berikutnya.
- v. Defendan hendaklah diberikan hak lawatan terhadap anak-anak tersebut semasa cuti persekolahan pada mana-mana waktu yang munasabah dengan memaklumkan kepada Plaintiff terlebih dahulu dan lawatan tersebut tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 6/11/2017, Alasan Rayuan pada 7/3/2018 dan Rekod Rayuan pada 2/4/2018. Selanjutnya Perayu telah memfailkan hujah pada 21/8/2018 dan Responden telah memfailkan hujahnya pada 1/11/2018.

[3] Perayu diwakili peguam syarie Tuan Musa b. Awang manakala Responden bertindak sendirian tanpa melantik mana-mana peguam syarie untuk mewakilinya di dalam kes rayuan ini.

FAKTA BERKAITAN PERBICARAAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[4] Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah 3 orang anak lelaki (2 orang kembar berumur 11 tahun dan seorang lagi berumur 4 tahun) terhadap Perayu melalui Saman bertarikh 9/9/2015. Serahan Saman kepada Perayu telah disempurnakan melalui tampalan di alamat terakhir berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS2003].

[5] Perayu tidak memfailkan sebarang Pernyataan Pembelaan dan kehadiran Perayu kali pertama di hadapan Mahkamah setelah perbicaraan telah dimulakan. Mahkamah telah menyoal 2 orang anak kembar yang telah mencapai umur mumayyiz berkaitan pilihan mereka pada 5/5/2016.

[6] Perayu telah menyatakan persetujuan bahawa hadhanah ketiga-tiga anak tersebut diserahkan kepada Responden pada tarikh perbicaraan 5/5/2016. Perbicaraan seterusnya dijalankan untuk menentukan hak lawatan Perayu terhadap anak-anak tersebut.

[7] YA Hakim Bicara telah memerintahkan pihak-pihak untuk memfailkan Affidavit Keterangan masing-masing untuk perbicaraan. Perayu telah gagal memfailkan sebarang Affidavit Keterangan dan telah memohon untuk memberikan keterangan secara lisan namun di tolak oleh YA Hakim Bicara. Pada 31/7/2017, Perayu gagal hadir ke Mahkamah untuk perbicaraan dan YA Hakim Bicara telah memerintahkan hak Perayu untuk memberi keterangan adalah dibatalkan dan kes ditangguhkan untuk keputusan pada siding selanjutnya. Pada 24/10/2017, keputusan telah diberikan dengan kehadiran Perayu dan Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Perayu telah memplid 5 alasan rayuan sepertimana di hal. 53-56 Rekod Rayuan;-

- i. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan bersalahan dengan kehendak peruntukan seksyen 100 dan/atau 101 **ETMMSS2003** apabila YA Hakim bicara menolak permohonan Perayu (defendan) pada 4/4/2017 untuk memberikan keterangan secara lisan sedangkan Perayu telah memohon maaf dan Perayu telah diperintahkan membayar kos kepada Responden (Plaintif) atas kegagalan Perayu memfailkan Affidavit Keterangan.
- ii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut undang-undang dan Hukum Syarak apabila YA Hakim tidak mendengar permohonan Perayu untuk pertukaran Hakim Bicara dan sebaliknya memerintahkan hak Perayu untuk memberikan keterangan dibatalkan.

- iii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan bersalahan dengan kehendak peruntukan seksyen 121 **ETMMSS2003** apabila membuat dan meneruskan penghakiman pada 24/10/2017 tanpa mengerahkan Responden mengangkat sumpah istizhar dalam mana keadaan Perayu telah dibatalkan haknya untuk memberikan keterangan.
- iv. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan Perayu diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah terhadap anak-anak tersebut dengan memaklumkan Responden terlebih dahulu dan lawatan tersebut tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut.
- v. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan Perayu diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah terhadap anak-anak tersebut dengan memaklumkan Responden terlebih dahulu dan meletakkan syarat tambahan “tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut” iaitu bagi ketiga-tiga anak tersebut.

[9] Sebelum kami mengulas berkenaan rayuan Perayu, kami ingin menarik perhatian kepada Notis Rayuan dan Alasan Rayuan yang difailkan oleh Perayu. Dalam Notis Rayuan, Perayu menyatakan merayu terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara bertarikh 24/10/2017 yang merangkumi perintah hak jagaan dan hak lawatan. Walaubagaimanapun, di dalam Alasan Rayuannya, Perayu hanya memplidkan kekhilafan YA Hakim

Bicara di dalam memutuskan perintah berkaitan hak lawatan sahaja kerana perintah berkaitan hak jagaan telah dikeluarkan atas persetujuan Perayu sebagaimana di dapati dalam catatan YA Hakim Bicara di hal. 22 Rekod Rayuan. Perayu sepatutnya lebih teliti dalam perkara ini agar tidak mengelirukan semua pihak dengan menentukan dengan tepat sama ada merayu keseluruhan atau sebahagian sahaja perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Di dalam memutuskan rayuan ini, Kami akan mengulas satu persatu alasan-alasan rayuan Perayu.

Alasan Pertama: YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan bersalahan dengan kehendak peruntukan seksyen 100 dan/atau 101 **ETMMSS2003** apabila YA Hakim bicara menolak permohonan Perayu (defendan) pada 4/4/2017 untuk memberikan keterangan secara lisan sedangkan Perayu telah memohon maaf dan Perayu telah diperintahkan membayar kos kepada Responden (Plaintif) atas kegagalan Perayu memfailkan Afidavit Keterangan.

[10] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak menerima permohonan Perayu pada prosiding bertarikh 4/4/2017 untuk memberikan keterangan secara lisan dan mengarahkan Perayu memberikan keterangan secara affidavit. Arahan YA Hakim Bicara tersebut adalah bercanggah dengan peruntukan seksyen 100 **ETMMSS2003** di mana diperuntukkan keterangan pihak-pihak hendaklah diberikan secara lisan di dalam Mahkamah. Perayu berhujah, pada prinsipnya keterangan pihak-pihak hendaklah diberikan secara lisan melainkan pihak-pihak atau saksi bersetuju untuk memberikan keterangan tersebut secara bertulis. Berdasarkan Rekod Rayuan, tiada sebarang catatan yang menunjukkan pihak-pihak telah memberikan persetujuan untuk keterangan diberikan secara bertulis.

[11] Perayu juga berhujah berdasarkan seksyen 101 Enakmen yang sama bahawa hanya saksi sahaja yang boleh memberikan keterangan secara bertulis dan perkataan saksi telah ditafsirkan di dalam seksyen 3 sebagai tidak termasuk Plaintiff, Defendan dan orang tertuduh. Perayu juga merujuk kepada autoriti kes *Zainab b. Mohd. Hussain lawan Latifah bt. Hassan & 9 Yang Lain, kes no. 10000-017-0022-2017* sebagai sokongan.

[12] Responden pula di dalam hujahnya menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah memberikan peluang seadilnya kepada Perayu untuk memfailkan Afidavit Keterangan walaupun Perayu gagal berbuat demikian pada tarikh 4/4/2017 dengan menangguhkan kes tersebut pada 31/7/2017. Namun Perayu telah gagal hadir pada tarikh perbicaraan 31/7/2017 menyebabkan YA Hakim bicara menetapkan kes tersebut untuk dimasukkan hujah dan diberikan keputusan pada tarikh akan datang.

[13] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan pihak-pihak. Kami bersetuju dengan Perayu bahawa Perayu sepatutnya diberikan hak untuk memberikan keterangan secara lisan berdasarkan seksyen 100 **ETMMSS2003** pada tarikh 4/4/2017 dan keputusan YA Hakim Bicara menolak permohonan Perayu adalah satu kekhilafan. Dengan hormatnya kami merujuk kepada seksyen 100 **ETMMSS2003**;-

“ Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 5/2003], apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah

dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka”

[14] Seksyen 101 **ETMMSS2003** memperuntukkan bahawa affidavit mana-mana saksi boleh dibacakan di dalam perbicaraan sekiranya Mahkamah berpendapat ianya munasabah untuk memerintahkan sedemikian. Kami juga telah meneliti autoriti kes *Zainab b. Mohd. Hussain lawan Latifah bt. Hassan & 9 Yang Lain* yang dikemukakan Perayu yang menyatakan pihak-pihak (Plaintif/Defendan) tidak boleh memberikan keterangan secara affidavit berdasarkan kedua-dua seksyen 100 dan 101 **ETMMSS2003**. Kami mendapati adanya amalan yang berlaku di dalam perbicaraan di mahkamah bawahan di mana pihak-pihak telah menyediakan affidavit keterangan sebelum perbicaraan dimulakan dan affidavit tersebut dikemukakan ketika memberikan keterangan secara lisan di hadapan Mahkamah. Keterangan secara affidavit tersebut akan diperiksa oleh pihak satu lagi melalui sesi soalbalas dan seterusnya disoal semula oleh pihak yang mengemukakan.

[15] Pada hemat kami, perbicaraan yang dijalankan melalui pengemukaan affidavit keterangan pihak-pihak ketika pemeriksaan lisan dijalankan adalah tidak bercanggah dengan seksyen 100 dan 101 **ETMMSS2003** dan kami dengan hormatnya kurang bersetuju dengan pendapat panel rayuan di dalam kes *Zainab b. Mohd. Hussain lawan Latifah bt. Hassan & 9 Yang Lain* tersebut. Realitinya, walaupun affidavit keterangan pihak-pihak dikemukakan namun keterangan secara lisan tetap juga diberikan dan pihak-pihak masih lagi tertakluk kepada prinsip pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula. Amalan pengemukaan affidavit keterangan

sebelum keterangan utama pihak-pihak diberikan boleh menjimatkan masa dan kos perbicaraan sesuatu kes dan ianya sama sekali tidak menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak.

Alasan Kedua: YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut undang-undang dan Hukum Syarak apabila YA Hakim tidak mendengar permohonan Perayu untuk pertukaran Hakim Bicara dan sebaliknya memerintahkan hak Perayu untuk memberikan keterangan dibatalkan.

[16] Perayu berhujah bahawa bahawa YA Hakim Bicara telah khilaf apabila tidak mendengar permohonan Perayu untuk pertukaran hakim bicara dan memerintahkan hak Perayu untuk memberikan keterangan dibatalkan. Perayu juga berhujah YA Hakim Bicara telah gagal memberikan penghakiman bertulis sebagaimana kehendak seksyen 130 ETMMSS2003.

[17] Responden berhujah bahawa Perayu hanya menghantar surat permohonan pertukaran hakim namun Perayu telah gagal hadir pada hari perbicaraan untuk beliau memberitahu secara lisan kenapa beliau ingin menukar Hakim Bicara. YA Hakim Bicara telah bertindak mengikut prosedur yang betul sehinggalah kes Responden tersebut diputuskan.

[18] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan malangnya kami tidak menjumpai apa-apa rekod berkaitan permohonan berkaitan pertukaran hakim. Malah dokumen surat permohonan yang dikatakan Perayu juga tidak kami jumpai.

[19] Sesuatu permohonan berkaitan pertukaran hakim merupakan satu permohonan interlocutori dan permohonan tersebut hendaklah dibuat berdasarkan seksyen 187 **ETMMSS2003** iaitu melalui pengemukakan Borang MS 49. Manakala seksyen 188(1) Enakmen yang sama memperuntukkan seperti berikut;-

(1) Sesuatu permohonan hendaklah disifatkan telah dibuat apabila notis berkenaan dengan permohonan itu telah difailkan dan dimeteraikan oleh seorang pegawai Pejabat Pendaftaran.

[20] Kami juga berpendapat bahawa Perayu telah terkhilaf berkaitan berkaitan peruntukan seksyen 130 **ETMMSS2003** dimana dalam pericaraan tersebut YA Hakim Bicara telahpun memberikan penghakiman bertulis dan penghakiman tersebut telahpun diumumkan pada 24/10/2017 dengan kehadiran Perayu (hal. 29 Rekod Rayuan).

[21] Kami juga mendapati bahawa YA Hakim Bicara juga telah bertindak di dalam kuasa budibicaranya apabila memutuskan bahawa hak Perayu untuk memberikan keterangan telah dibatalkan kerana ketidakhadiran Perayu pada tarikh perbicaraan 31/7/2017 dan juga kegagalan Perayu mematuhi arahan pemfailan affidavit keterangan yang dikeluarkan sebelumnya (hal. 28 Rekod Rayuan). Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami menolak Alasan Rayuan Kedua Perayu.

Alasan Ketiga: YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan bersalahan dengan kehendak peruntukan seksyen 121 **ETMMSS2003** apabila membuat dan meneruskan penghakiman pada 24/10/2017

tanpa mengarahkan Responden mengangkat sumpah istizhar dalam mana keadaan Perayu telah dibatalkan haknya untuk memberikan keterangan.

[22] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memerintahkan Responden bersumpah istizhar berdasarkan seksyen 121(2) **ETMMSS2003** kerana penghakiman diteruskan tanpa kehadiran Perayu dan hak Perayu untuk memberikan keterangan telah dibatalkan. Perayu juga merujuk kepada seksyen-seksyen 72 dan 87(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 mengenai keperluan untuk bersumpah.

[23] Kami ingin menarik perhatian bahawa status Perayu di dalam perbicaraan di mahkamah bicara bukanlah sebagai seorang yang tidak hadir (*al-gha'ib*) dan prosiding yang dijalankan terhadap Perayu bukanlah prosiding tanpa kehadiran (*al-qadha' ala al-gha'ib*) yang mewajarkan sumpah istizhar diperlukan sebelum penghakiman mengikut Hukum Syarak. Perayu telah hadir semasa prosiding perbicaraan dan telah menggunakan haknya untuk menyoalbalas Responden dan saksi-saksi Responden (hal. 26 Rekod Rayuan). Tambahan pula, isu yang dibicarakan bukanlah berkaitan hak penjagaan anak bahkan berkaitan hak lawatan anak.

[24] Berdasarkan Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Responden telah mengemukakan 2 orang saksi untuk menyokong tuntutan. Pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah berpuashati dengan tahap pembuktian yang dikemukakan oleh pihak Responden dan penghakiman boleh diberikan tanpa

memerlukan kepada aplikasi sumpah. Justeru itu, Alasan Rayuan Ketiga Perayu adalah ditolak.

Alasan Keempat : YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan Perayu diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah terhadap anak-anak tersebut dengan memaklumkan Responden terlebih dahulu dan lawatan tersebut tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut; dan

Alasan Kelima : YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah khilaf dari sudut Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan Perayu diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah terhadap anak-anak tersebut dengan memaklumkan Responden terlebih dahulu dan meletakkan syarat tambahan “tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut” iaitu bagi ketiga-tiga anak tersebut.

[25] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak apabila menetapkan hak lawatan tanpa bermalam sahaja kepada Perayu terhadap anak-anak tersebut. Hak lawatan tersebut juga hanya boleh dilaksanakan dengan mengambilkira kehendak anak-anak tersebut. Perayu menyatakan bahawa syarat yang dikenakan dalam perintah Mahkamah adalah tidak adil kepada Perayu lantaran hubungan semasa antara Perayu dan anak-anak adalah tidak begitu rapat dan dibimbangi usaha-usaha Perayu untuk memulihkan hubungannya dengan anak-anak tersebut tidak akan berjaya tanpa diberikan hak lawatan yang panjang termasuklah hak untuk bermalam. Perayu merujuk kepada seksyen 88

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan agar pihak yang tidak diberikan hak jagaan boleh diberikan hak untuk berjumpa dengan anak-anak pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang munasabah.

[26] Sebagaimana yang diujahkan oleh Perayu sebelum ini bahawa Perayu telah dibatalkan haknya untuk memberikan keterangan di dalam perbicaraan di mahkamah bicara kerana kegagalan Perayu untuk hadir pada tarikh perbicaraan yang ditetapkan. Oleh yang demikian, YA Hakim Bicara mempunyai keterangan yang terhad kepada pihak Responden sahaja.

[27] Kami telah meneliti dokumen-dokumen Afidavit Keterangan Plaintiff dan Afidavit Keterangan Saksi-Saksi Plaintiff di hal.30-37 Rekod Rayuan dan mendapati terdapat di dalamnya keterangan dan alasan-alasan yang konsisten telah diberikan Responden dan saksi-saksinya kenapa hak bermalam tidak wajar diberikan kepada Perayu. Dengan itu, Alasan Rayuan Keempat dan Kelima Perayu juga ditolak.

[28] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa semasa kes rayuan ini didengar oleh kami, umur anak-anak telahpun meningkat melepasi umur mumayyiz di mana Muhammad Rayyan Adam telah berumur 8 tahun manakala Mohamad Haikal Firdaus dan Mohamad Ikmal Firdaus telahpun berumur 15 tahun. Walau apapun kekhilafan yang dikatakan berlaku semasa perbicaraan terdahulu, kami berpendapat penentuan hak dan terma lawatan yang bersesuaian dan adil tidak dapat ditentukan oleh kami hari ini kerana kami tidak berpeluang untuk mendengar dan meneliti keterangan langsung

pihak-pihak. Korum yang sesuai pada hemat kami untuk menentukan hal tersebut adalah korum di dalam kes perubahan perintah yang boleh dimohon oleh pihak-pihak di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 di mahkamah bicara.

[29] Sebagai penutup, kami kemukakan pandangan panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob*[2004] JH17(1)19 sebagai renungan bersama;-

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, maka kami **sebulat suara** memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.

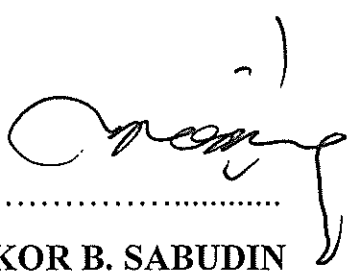
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



10

)